

1500137-35.2022.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Truite Alves

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/07/2022

... mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas). ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500137-35.2022.8.26.0551 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500137-35.2022.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2083205/2022 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 23869501 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 35/22/819 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2083205 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS FILHO e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Truite Alves

Vistos.

FELIPE SANTOS PEREIRA BARBOSA FILHO, PAULO HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS FILHO e WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA BATISTA, qualificados nos autos, estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o artigo 29 do Código Penal.

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 25 de março de 2022, por volta das 15 horas, na Avenida Higino de Barros Camargo, nº 1, Parque Hippolyto II, na cidade e comarca de Limeira, FELIPE, previamente ajustado e com unidade de

desígnios com PAULO HENRIQUE e WELLINGTON, traziam e tinham em depósito, para fins de tráfico, 126 porções de cocaína, pesando no total 46,41g, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo químico-toxicológico definitivo.

Apurou-se que, na data dos fatos, os acusados deliberaram a realização da venda de drogas na cidade de Limeira, dividindo as tarefas. FELIPE mantinha consigo parte dos entorpecentes e certa quantia monetária, além de manter em depósito o restante do entorpecente, realizando a comercialização direta, enquanto PAULO HENRIQUE e WELLINGTON, aderindo à conduta de FELIPE, permaneceram posicionados em dois pontos estratégicos, nas proximidades do local onde a venda era realizada, visando informar, através de contato via aparelho celular, a presença de agentes das forças de segurança pública.

Ocorre que guardas municipais receberam informações da venda de drogas por um indivíduo e da existência de outros dois na condição de "olheiros". Desta forma, os agentes públicos se dirigiram até o local e depararam-se com PAULO HENRIQUE, que ao avistar a viatura falou no celular "molhou, é a Romu", comunicando aos demais denunciados a presença das forças de segurança. Realizada a abordagem, em seu poder foi encontrado apenas um aparelho celular.

Ato contínuo, FELIPE, que estava nas proximidades, correu em direção a uma área verde, sendo também detido pelos guardas municipais. Realizada revista pessoal, no bolso da bermuda de FELIPE, os agentes públicos localizaram 26 porções de COCAÍNA, a quantia de R\$80,00 e um aparelho celular.

Indagado, FELIPE admitiu que praticava o tráfico de drogas e confirmou que PAULO HENRIQUE lhe auxiliava como "olheiro", noticiando ainda que WELLINGTON exercia a mesma função, mas em uma passarela da via Anhanguera.

Diante de tais informações, os guardas foram até a referida passarela e ali avistaram WELLINGTON, este ao avistar os agentes públicos correu, sendo perseguido e abordado. Em sua posse foi localizado um aparelho celular.

Por fim, FELIPE indicou a existência de mais droga em uma área verde, onde se localizou outras 100 porções de cocaína.

Os denunciados foram presos em flagrante.

Interrogados, FELIPE admitiu a propriedade das drogas encontradas em seu poder, confirmou que se destinavam à venda e relatou que contratou PAULO HENRIQUE e WELLINGTON para auxiliar na prática delitiva, avisando-o da chegada da polícia. WELLINGTON corroborou a versão de FELIPE, enquanto PAULO HENRIQUE ficou em silêncio.

Oferecida à denúncia, determinou-se a notificação dos réus para que apresentassem defesas preliminares, que vieram aos autos (fls. 165/166).

A denúncia foi recebida em 27 de maio de 2022 (fls. 167/168).

Durante a audiência de instrução, foram ouvidas as testemunhas e os réus interrogados ao final. (mídia).

Encerrada a instrução, as partes manifestaram-se.

Alegações finais orais do Ministério Público (mídia) e memoriais escritos dos acusados FELIPE e WELLINGTON (fls. 195/202) e do corréu PAULO HENRIQUE (fls. 221/226).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Não há preliminares pendentes de apreciação.

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 09/10), boletim de ocorrência (fls. 20/22), auto de exibição e apreensão (fls. 23/24), laudo pericial com resultado positivo para "cocaína" (fls. 26/28 e 125/127), bem como pela prova oral colhida no curso da persecução penal.

A autoria é certa.

Perante a autoridade policial, o acusado FELIPE disse que as 26 porções de "cocaína" apreendidas na sua posse são suas e admitiu que estava no local vendendo "cocaína". Vendia cada porção a dez reais. Sobre os acusados Paulo Henrique e Wellington são seus conhecidos e informou que os contratou para ficar "na campana", ou seja, a função deles era avisar o acusado sobre a presença da polícia. Não revelou a identidade da pessoa que lhe fornece as drogas. Esclareceu que estava vendendo drogas para sustentar seu vício em "cocaína", "maconha", bebida alcoólica, cigarros e também para conseguir algum dinheiro, pois sua ex-namorada está grávida de gêmeos e o acusado é o pai (fls.14).

Em juízo, o acusado FELIPE disse que tem 20 anos. Trabalhava com reciclagem. Estava vendendo drogas no dia da prisão. Tinha em seu poder 26 pinos. Outros rapazes estavam juntos. Ligaram para ele avisando que a guarda iria prendê-lo. Assumiu os pinos em seu poder e o dinheiro. Wellington foi preso. Paulo Henrique também foi detido. O que acharam nas proximidades não era seu. Só tinha 26 pinos. Não irá citar o nome de Paulo Henrique e Wellington. Confirma que estava traficando, já iria terminar o serviço. Na infância teve passagem por tráfico, no ano passado foi preso e saiu de novo. Não foi julgado nesse processo. Fazia três dias que voltou a vender drogas. Ficou provisoriamente internado e ganhou liberdade assistida em 2019. Teve mais um processo na infância por tráfico, foram dois processos ao todo, já chegou a ficar internado (mídia).

Perante a autoridade policial, o acusado PAULO HENRIQUE permaneceu silente a respeito dos fatos (fls. 15).

Em juízo, o acusado PAULO HENRIQUE disse que tem 23 anos. Trabalhava com calhas. Não conhece os demais acusados. Sua namorada mora na rua. Desceu para catar o ônibus no ponto, havia outro moleque. Foi colocado dentro da viatura. Não avisou Felipe por telefone. Só ficou sabendo o que acontecia depois que entrou na viatura. Responde a outro processo por uso de drogas. Na infância teve passagem por tráfico e ficou internado quando tinha 17 anos (mídia).

Perante a autoridade policial, o acusado WELLINGTON disse que estava trabalhando como olheiro do tráfico para o acusado Felipe. Sua função era ficar na passarela da Rodovia anhanguera e avisar Felipe pelo celular se avistasse alguma viatura. Felipe promete pagar cem reais para ficar nessa função das 10 horas da manhã até às 16 horas. A data dos fatos foi a primeira vez que fez tal trabalho. O acusado ficou o dia inteiro na passarela, mas não precisou avisar Felipe nem uma vez. Estava lá quando percebeu que estava sendo cercado pelos guardas municipais. Tentou fugir, mas foi alcançado e preso. Estava apenas com um telefone celular. O denunciado não usa droga e está desempregado, desde quando foi demitido da empresa coperfield, onde trabalhou por quase sete anos, como operador de máquina CNC, tendo sido demitido em 2020, devido a pandemia (fls.16).

Em juízo, o acusado WELLINGTON disse que tem 27 anos. É operador de máquinas e torneiro mecânico. Não conhecia os demais acusados. Foi trabalhar de olheiro. Estava desempregado. Ficou sentado na ponte, viu a viatura. Ficou desesperado e correu. Depois se rendeu. Não tem antecedentes criminais. Quando era adolescente não teve passagens (mídia).

Vejamos o teor da prova testemunhal.

O guarda civil municipal Osvaldo Moreira Junior disse que o local da prisão é conhecido por ser ponto de venda de drogas. É normal o ingresso de duas ou mais pessoas que se unem para vender drogas naquele local. Receberam denúncia na base da Guarda Civil Municipal. Foram até o local, a denúncia mencionava três pessoas divididas na rua, um na ponta, outro no meio como vendedor e outro olheiro, os três envolvidos fazendo uso de telefones celulares. Surpreenderam de início o acusado Paulo Henrique, o qual avisou a presença dos guardas civis a um dos comparsas. A outra equipe abordou o réu Felipe, vendedor de drogas, que tentou fugir. No bolso dele havia 26 pinos de cocaína. Com Paulo Henrique só tinha um telefone celular. Felipe disse que vendia drogas e havia uma quantia em dinheiro em seu poder. Ele disse que vendia em conjunto com os acusados Paulo Henrique e Wellington. Prenderam Wellington na passarela, ele tentou fugir pela rodovia e quase causou um acidente de trânsito. Com ele localizou um telefone celular, ele disse que iria avisar a presença dos policiais aos demais. Todos estavam unidos na venda de drogas. Felipe era o vendedor e contou que perto da passarela havia mais drogas. Encontraram mais 100 pinos de cocaína idênticos ao encontrado no bolso dele. A passarela onde Wellington estava é longe do local da prisão, é um local privilegiado para informar os demais envolvidos e ali há venda de drogas para caminhoneiros que circulam pela rodovia. A passarela dá acesso à avenida em questão. Paulo Henrique estava perto de um ponto de ônibus (mídia).

O guarda civil municipal Edilson Dias de Souza contou que estavam de serviço e receberam informação na base da Guarda Civil Municipal apontando que no local em questão havia três pessoas comercializando drogas. Um ficava no meio da avenida vendendo entorpecentes, o outro estava no ponto de ônibus informando a presença da viatura e havia mais um terceiro de olheiro. No ponto indicado avistou o acusado Paulo Henrique. Ao perceber a presença da viatura, ele informou a presença por telefone celular ("molhou, é a Romu"). Felipe estava mais para frente e vendia drogas. Ele tentou fugir, mas foi abordado. Encontraram dinheiro, aparelho celular e porções de cocaína em seu poder. Na passarela que atravessa a rodovia havia mais uma pessoa envolvida. Fizeram o cerco. Quem informou a presença de Wellington na passarela foi Felipe. Eram duas pessoas ajudando Felipe, todos estavam unidos no tráfico. Wellington saiu correndo pela rodovia e foi alcançado por um colega de farda. Deram voz de prisão. Foi noticiado que havia mais drogas e perto da ponte localizaram mais cem porções de cocaína. Quem indicou os flaconetes foi Felipe. Paulo Henrique e Wellington disseram que ganhavam cem reais para informar a presença de viatura a Felipe. Já conhecia Felipe e Paulo Henrique, não conhecia Wellington. Felipe foi apreendido quando era menor de idade (mídia).

Quanto à ação dos guardas municipais, tem-se que perfeitamente válida. É cediço que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal estabelece que a guarda municipal será destinada apenas à proteção de bens, instalações e serviços dos Municípios, não tendo ela, portanto, a função de garantir a segurança, bem como investigar a prática de crimes. No entanto, referida limitação não significa que a guarda municipal não possa prender em flagrante quem estiver cometendo um delito.

"(...) 2. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos

depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE – Rel. Min. Carlos Ayres Brito – j. 05.09.06; HC 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello – DJU 18.10.96; HC 70.237 – Rel. Min. Carlos Velloso – RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP – Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – j. 06.06.13; HC 177.980/BA – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 28.06.11; HC 149.540/SP – Rel. Min. Laurita Vaz – j. 12.04.11 e HC 156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP – Rel. Min. Moura Ribeiro – j. 27.05.14; RHC 45.173/SP – Rel. Min. Jorge Mussi – j. 26.05.14 e HC 109.105/SP – Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima – j. 23.02.10). (...)" (TJSP; Apelação 0003302-14.2014.8.26.0627; Relator (a): Airton Vieira; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Teodoro Sampaio - Vara Única; Data do Julgamento: 31/10/2017; Data de Registro: 06/11/2017).

Pelo teor da prova oral, guardas civis municipais receberam informações de tráfico de drogas envolvendo três pessoas, um deles na condição de vendedor e os demais como olheiros.

Então, os agentes públicos foram ao local indicado e depararam-se com PAULO HENRIQUE que, ao avistar a viatura falou em um aparelho celular "molhou, é a Romu", comunicando aos demais acusados a presença dos agentes. Foi realizada a abordagem e em revista pessoal foi encontrado com PAULO HENRIQUE apenas um aparelho celular.

Na sequência, o acusado FELIPE, que estava nas proximidades, tentou fugir, mas foi detido pelos guardas. Realizada revista pessoal, foram localizados 26 (vinte e seis) porções de cocaína, quantia em dinheiro e um aparelho celular.

O réu FELIPE, ao ser indagado pelos agentes públicos, confessou a prática delitiva voltada ao tráfico de drogas e confirmou que os acusados WELLINGTON e PAULO HENRIQUE atuavam na traficância com ele. FELIPE também indicou a existência de mais 100 (cem) porções de cocaína.

Os guardas civis municipais foram até a referida passarela e avistaram o réu WELLINGTON. Ao avistar os agentes, ele correu, mas foi detido. Em revista pessoal foi localizado um aparelho celular.

Os acusados foram presos em flagrante delito na posse de drogas, dinheiro e telefones celulares.

Desse modo, o conjunto probatório é harmônico, robusto e conclusivo quanto à autoria do crime de tráfico envolvendo os acusados FELIPE, PAULO HENRIQUE e WELLINGTON, haja vista a quantidade, a natureza e a forma como estavam embaladas as drogas (cocaína), a denúncia anônima, as circunstâncias da prisão, o depoimento incriminador dos guardas municipais e a confissão extrajudicial dos réus FELIPE e WELLINGTON, tudo a aponta-los como sendo pessoas envolvidas no tráfico de drogas.

Sobre o tema em comento, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo é remansosa:

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006 - Absolvição ou, ainda, desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei de Drogas - Descabimento - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Palavra dos policiais militares - Credibilidade - Precedentes - Destinação mercantilista do entorpecente apreendido evidenciada pelas circunstâncias fáticas da prisão - Ausência de visualização de atos de mercancia - Irrelevância - Tipo misto ou de conteúdo variado - Condenação mantida (...) ". (TJSP; Apelação 0004568-50.2015.8.26.0126; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/09/2017; Data de Registro: 11/10/2017).

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES. (...) Materialidade e autoria delitiva comprovadas, sobretudo diante dos relatos seguros dos policiais militares que participaram da diligência. Escusa ofertada pelo réu isolada no quadro probatório. Impossibilidade de desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Condenação mantida (...)". (TJSP; Apelação 0000137-25.2017.8.26.0571; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapetininga - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 01/03/2018).

"APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADA, EM RELAÇÃO AO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO, INCONSISTENTE A NEGATIVA DE AUTORIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, LOCAL DA ABORDAGEM, CONHECIDO PONTO DE VENDA DE ENTORPECENTES, MODO COMO OS ESTUPEFACIENTES ESTAVAM EMBALADOS, QUANTIDADE SIGNIFICATIVA E NATUREZA ALTAMENTE NOCIVA COMPATÍVEIS COM O TRÁFICO(...) (TJSP; Apelação 0002975-45.2014.8.26.0344; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 9ª Câmara Criminal Extraordinária; Foro de Marília - 3ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 15/09/2017; Data de Registro: 26/09/2017).

Segundo entendimento do saudoso Luiz Flávio Gomes:

"Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (GOMES, Luiz Flávio e CUNHA. Rogério Sanches (Coordenadores). Legislação Criminal Especial. Volume 6. São Paulo: Editora RT, 2009).

Não há que se falar em desclassificação do delito de tráfico de drogas para o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, principalmente em razão da quantidade e natureza das drogas apreendidas, assim como as circunstâncias da prisão em flagrante, existindo depoimento incriminador de agentes públicos envolvendo os réus.

Na esteira dos ensinamentos de Cleber Masson:

"Os critérios mencionados devem ser aferidos conjuntamente. Apenas um deles, isoladamente, nem sempre conduzirá o intérprete a adotar a melhor solução. Perceba-se, por curial, que uma quantidade relativamente pequena de droga não indica, necessariamente, que o sujeito ativo a tem para consumo pessoal. Como se sabe, é cada dia mais incomum a existência de grandes depósitos de drogas. Os traficantes, justamente para dificultar a ação repressiva do Estado, têm preferido muitas vezes trabalhar com pequenas quantidades distribuídas entre várias "mulas " (MASSON,

Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Não é diferente o posicionamento jurisprudencial:

"Tráfico de entorpecentes – Dolo de traficar – Desclassificação para porte de entorpecentes (art. 28 da Lei n. 11.343/06) – Descabimento Provado o dolo genérico de traficar, tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/06, não cabe a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/06, se for observado que as demais circunstâncias que cercaram a prisão do acusado dão conta da caracterização do tráfico de entorpecentes (...)" (TJSP; Apelação 0002093-84.2015.8.26.0300; Relator (a): Grassi Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jardinópolis - 2ª Vara; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 06/03/2018).

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas. Apreensão de porções de "maconha", "crack" e cocaína. Sentença condenatória. Defesa requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente pretende a desclassificação para consumo pessoal, o reconhecimento da figura privilegiada, o abrandamento do regime prisional, a substituição da carcerária por restritivas de direitos e a inconstitucionalidade da pena de multa. Materialidade e autoria indubitáveis. Réu preso em flagrante na posse de entorpecentes, na via pública, após delação anônima feita aos policiais. Quantidade e diversidade denotam a traficância.(...)" (TJSP; Apelação 0005361-26.2016.8.26.0361; Relator (a): Carlos Monnerat; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi das Cruzes - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 14/12/2017; Data de Registro: 19/12/2017).

Não se exige a existência do efetivo comércio para a configuração do crime do artigo 33, caput, da Lei de Drogas. Basta a guarda, o transporte, o trazer consigo, ou a manutenção em depósito, com a finalidade de distribuição ou de entrega a terceiros para que o crime se consuma.

A lei penal pune a mera finalidade (intenção) mercantil da posse e da guarda da droga como tráfico consumado. O mero fato de o agente guardar ou ter em depósito drogas, ainda que a mando de terceiros, mesmo que sem intuito de lucro, configura o crime de tráfico de drogas, pois o tipo penal prevê como tráfico as condutas de guardar e ter em depósito, ainda que gratuitamente (art. 33, caput, Lei de Drogas).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública, de modo que é condenável a simples possibilidade de distribuição, gratuita ou onerosa, do entorpecente.

Em comentários ao artigo 33 da Lei de Drogas, o saudoso Luiz Flávio Gomes preleciona:

"(...) Deve ser lembrado que algumas modalidades são permanentes, protraindo o seu momento consumativo no tempo e no espaço (p.ex., expor à venda, trazer consigo, manter em depósito, guardar etc.). A multiplicidade de condutas incriminadas parece inviabilizar a tentativa (...)" (GOMES, Luiz Flávio et al. Nova Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo: Lei 11.343/06 de 23.08.2006. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006).

É esse o caso dos autos.

Não se cogita em desclassificação para o artigo 37 da Lei de Drogas (informante colaborador). PAULO HENRIQUE e WELLINGTON não exerceram a função de mero "olheiro". As provas colhidas demonstram a ligação deles com o hediondo comércio, atuando ativamente no tráfico ilícito de drogas, participando diretamente da própria

execução do crime em divisão de tarefas com FELIPE, o que não se confunde com a conduta prevista no artigo 37 da Lei nº 11.343/06, de mero prestador de informações.

Como conclui Cleber Masson:

"Em verdade, nem toda espécie de colaboração é englobada pelo art. 37 da Lei de Drogas. De fato, a "colaboração material" normalmente acarreta em verdadeiro auxílio ao narcotráfico, fazendo com que o "colaborador" seja considerado partícipe do tráfico de drogas. Além disso, também é possível cogitar da participação no tráfico de drogas pela "colaboração moral", quando então o sujeito será alcançado pela norma de extensão pessoal contida no art. 29, caput, do Código Penal, por ter instigado ou induzido o autor deste delito. Finalmente, a colaboração mediante financiamento ou custeio ao tráfico de drogas pode configurar o delito tipificado no art. 36 da Lei 11.343/2006" (MASSON, Cleber. Lei de Drogas: aspectos penais e processuais. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2019).

Demonstrada a procedência da imputação contra os acusados FELIPE, PAULO HENRIQUE e WELLINGTON, não existindo justificativas para os seus atos, passo à dosimetria das penas a serem aplicadas a eles.

FELIPE SANTOS PEREIRA BARBOSA FILHO

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis ao réu, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Segundo entendimento firmado pelo STF em sede de repercussão geral (STF, ARE 666334 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-084 DIVULG 05-05-2014 PUBLIC 06-05-2014), fica vedada a utilização da natureza e da quantidade da droga, cumulativamente, para majorar a pena-base, na primeira fase, e, na terceira, para modular a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, sob pena de indevido bis in idem.

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Na terceira fase, observo que o réu Felipe possui histórico de atos infracionais quando da sua menoridade (cf. autos nº 1513868-20.2019.8.26.0320 e 1513167-59.2019.8.26.0320- fls. 61), fato assumido quando interrogado judicialmente, todos os expedientes envolvendo tráfico de drogas, com vasta quantidade de drogas apreendidas, o que denota dedicação à atividade criminosa, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, na linha da jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO APLICAÇÃO. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO. 1. A aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com o consequente reconhecimento do tráfico privilegiado, exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. 2. Os atos infracionais também podem ser considerados como elementos de convicção de que o agente se dedica à prática delituosa e, portanto, podem ser utilizados para justificar o afastamento do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 3. Agravo regimental

provido. (STJ, AgRg no REsp 1873094/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES ILÍCITAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. (...). IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade de entorpecentes apreendidos, assim como pelo fato de que o paciente já respondeu por atos infracionais análogos ao crime de tráfico de entorpecentes, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demonstram que o paciente se dedicava às atividades criminosas (...) Agravo regimental desprovido". (STJ, AgRg no HC 604.121/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PRÁTICA ANTERIOR DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 3. Na hipótese, o pretendido redutor foi afastado com fundamento não só na quantidade e na diversidade do entorpecente apreendido mas também na anterior prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no HC 588.716/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 28/08/2020).

"(...) - O ora paciente conta com condenação anterior à medida socioeducativa de internação, pela prática do ato infracional equiparado ao tráfico de entorpecentes. Dessa forma, sobeja essa razão, idônea nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, para afastar a redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois atesta a dedicação do acusado à atividade criminosa (...) Habeas corpus não conhecido." (STJ, HC 481.232/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

Apesar da defesa afirmar que o Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a utilização de atos infracionais não constitui fundamentação idônea para afastar a aplicação da figura do tráfico privilegiado, a questão não é pacífica e encontra divergência no âmbito das duas turmas da Suprema Corte, em conformidade com os julgados que cito abaixo:

"Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Pretendida aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido." (STF, HC 192147 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 19-04-2021 PUBLIC 20-04-2021).

"Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido." (STF, RHC 190434 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 12-11-2021 PUBLIC 16-11-2021).

"Habeas corpus. (...) Redutor. Tráfico privilegiado. Existência de ato infracional. (...)1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, "[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006" (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 31/10/14). (...) (STF, HC 195540, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 13-08-2021 PUBLIC 16-08-2021).

No mesmo sentido, confira-se: STF, HC 206922, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 24/09/2021, publicado em 27/09/2021.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas (126 porções de cocaína, pesando no total 46,41g), nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440/STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem:

Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional das penas em função da vedação do art. 44 da Lei nº 11.343/2006.

PAULO HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS FILHO

As circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei nº 11.343/2006 são favoráveis ao réu, devendo a pena-base ser fixada no mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Na terceira fase, observo que o réu Paulo Henrique possui histórico de atos infracionais quando da sua menoridade (cf. autos nº 0023794-75.2014.8.26.0320, 0017992-62.2015.8.26.0320, 0025407-96.2015.8.26.0320, 0025919-79.2015.8.26.0320, 0001506-65.2016.8.26.0320, 0000360-72.2016,8,26,0320 – fls. 189/190), fato assumido quando interrogado judicialmente, alguns expedientes envolvendo tráfico de drogas, com vasta quantidade de drogas apreendidas, o que denota dedicação à atividade criminosa, não sendo caso de incidência do redutor previsto em lei, na linha da

jurisprudência consolidada já mencionada acima.

Não havendo outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Fixo cada dia-multa no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial semiaberto, em razão da natureza e quantidade das drogas apreendidas (126 porções de cocaína, pesando no total 46,41g), nos termos do artigo 42 da Lei de Drogas, sem a aplicação do redutor previsto em lei conforme acima mencionado.

Inadmissível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos por força da restrição imposta pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, bem como pela suspensão condicional da pena em função da vedação do art. 44 da Lei nº 11.343/2006.

WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA BATISTA

Concernente ao crime de tráfico de drogas, as circunstâncias judiciais dos artigos 59, do Código Penal, e 42, da Lei nº 11.343/2006, são inteiramente favoráveis ao réu, devendo a pena-base partir do mínimo legal, isto é, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há agravantes. Por outro lado, deixo de aplicar qualquer atenuante, pois a pena-base já foi estabelecida no patamar mínimo, observando-se o teor da Súmula nº 231 do Colendo STJ.

Ausentes quaisquer causas de aumento.

Na terceira fase, sendo o réu primário e portador de bons antecedentes, aplico a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4ª, da Lei nº 11.343/2006, reduzindo a reprimenda em 2/3 (dois terços), tornando-se definitiva a pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, além de pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Para que fique bem claro, na derradeira etapa do sistema trifásico, deve ser levada em consideração a causa especial de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, causa esta que, uma vez verificados seus requisitos, deve ser aplicada.

A este respeito, deve ser acolhido o seguinte preceito doutrinário:

“Dispõe o parágrafo, em sua parte final, sobre condições negativas de que o agente não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Toda prova negativa é difícil, de modo que militará em favor do réu a presunção de que é primário e de bons antecedentes e de que não se dedica a atividades criminosas nem integra organização criminosa. O ônus da prova, no caso, é do Ministério Público no sentido de demonstrar a reincidência, os maus antecedentes e a participação em atividades criminosas ou organização criminosa. Não importa que a prova seja difícil para o Ministério Público. Mais difícil seria para o réu que, por sua vez, tem o direito de não ser condenado a não ser que haja prova, ou receber, sem prova, uma pena maior quando a lei permite uma pena mais branda” (GRECO FILHO, Vicente e RASSI, João Daniel. Lei de Drogas Anotada. São Paulo: Saraiva, 2008).

Apesar do entendimento em contrário deste julgador, observo que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo, nas duas turmas existentes, que inquéritos policiais ou ações penais ainda sem a certificação do trânsito em julgado não constituem fundamento idôneo a afastar o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, em observância ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade.

A respeito do assunto, cito os seguintes precedentes:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO: FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (STF, HC 170392 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 12-06-2020 PUBLIC 15-06-2020).

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, a existência de inquéritos ou ações penais em curso não constitui fundamento válido para afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas. 3. Agravo regimental desprovido”. (STF, HC 177670 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 22-09-2020 PUBLIC 23-09-2020).

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes. Condenação. 4. Causa de diminuição de pena do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 5. Não aplicação da minorante em razão de sentença sem trânsito em julgado. 6. Ré primária. 7. Ausência de provas de que integra organização criminosa ou se dedique à prática de crimes. 8. Decisão contrária à jurisprudência desta Corte. Constrangimento ilegal configurado. 8.1. O Pleno do STF, ao julgar o RE 591.054/SC, com repercussão geral, de relatoria do Ministro Marco Aurélio (DJe 26.2.2015), firmou orientação no sentido de que a existência de inquéritos policiais ou de ações penais sem trânsito em julgado não pode ser considerada como Maus Antecedentes para fins de dosimetria da pena. 8.2. Para efeito de aumento da pena, somente podem ser valoradas como Maus Antecedentes decisões condenatórias irrecorríveis, sendo impossível considerar para tanto investigações preliminares ou processos criminais em andamento, mesmo que estejam em fase recursal, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LIV (presunção de não culpabilidade), do texto constitucional. 9. Precedentes. 10. Agravo regimental não provido”. (STF, ARE 1231853 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 03/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 17-03-2020 PUBLIC 18-03-2020).

“PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. O Pleno do Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 591.054, de minha relatoria, assentou a neutralidade, na definição dos antecedentes, de inquéritos ou processos em tramitação, considerado o princípio constitucional da não culpabilidade. PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO – PROCESSOS EM CURSO. Revela-se inviável concluir pela dedicação do acusado a atividades criminosas, afastando-se a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, considerado processo-crime em tramitação”. (STF, HC 173806, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049 DIVULG 06-03-2020 PUBLIC 09-03-2020).

Há recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: STJ, HC 602.611/DF, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 24/11/2020.

O valor do dia multa será no mínimo legal.

Considerando o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no acórdão proferido no

HC 118.553/MS, no sentido de que o delito de tráfico de drogas privilegiado não possui natureza hedionda, revejo meu entendimento para admitir à fixação de regime inicial carcerário mais brando aos condenados pela prática daquela infração penal.

De fato, o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos.

A obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 1º do art. 2º da Lei nº 8.072/1990, pelo STF, no julgamento do HC 111.840/ES.

Dessa forma, fixo o regime inicial aberto para o caso em questão.

Para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, conforme Súmulas 440/STJ e 718 e 719 do Colendo STF, que assim dispõem:

Súmula 440/STJ: Fixada a pena-base no mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base apenas na gravidade abstrata do delito.

Súmula 718/STF: A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.

Súmula 719/STF: A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.

No mais, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, aplica-se a Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) na fixação do regime prisional, assim como as decisões dos Tribunais Superiores (STF e STJ).

Ante a quantidade da pena imposta, a primariedade e tendo em vista a decisão do STF no sentido de que o tráfico privilegiado não pode ser considerado como crime hediondo, além da natureza, estando presentes os requisitos que autorizam a medida, substituto a pena privativa de liberdade de WELLINGTON por duas restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de um salário mínimo, a ser definida em sede de execução criminal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR os acusados FELIPE SANTOS PEREIRA BARBOSA FILHO e PAULO HENRIQUE APARECIDO DOS SANTOS FILHO, qualificados nos autos, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, com pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor, cada um, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art. 43 da Lei nº 11.343/06. Isto por considera-los incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c.c. o art. 29 do Código Penal.

Por outro lado, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu WELLINGTON HENRIQUE DA SILVA BATISTA, qualificado nos autos, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, no seu menor valor, como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 c/c a redução prevista no §4º do art. 33 ambos da mesma lei, substituída a pena corporal por penas alternativas acima mencionadas.

Fixado o regime inicial semiaberto, não se mantém a prisão preventiva. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o HC nº 181.534, de Relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, publicado em 02/03/2020, "eventual manutenção da prisão preventiva em regime semiaberto, além de carecer de amparo

legal, desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado pelas instâncias ordinárias".

Na mesma direção:

"PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II - Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário". (STF, HC 138122, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017).

"HABEAS CORPUS" - PRISÃO PREVENTIVA - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA QUE MANTÉM O DECRETO PRISIONAL - ESTIPULAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR COM O REGIME SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA - A PRISÃO PREVENTIVA IMPOSTA AO PACIENTE CONSTITUI MEDIDA CONSTRITIVA DE LIBERDADE MAIS GRAVOSA QUE A PRÓPRIA PENA A QUE FOI CONDENADO - OFENSA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE NORTEADORES DE TODA E QUALQUER INTERVENÇÃO DO PODER PÚBLICO NO CAMPO DAS LIBERDADES FUNDAMENTAIS EM NOSSO PAÍS - "HABEAS CORPUS" NÃO CONHECIDO, MAS CONCEDIDO DE OFÍCIO - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO". (STF, HC 185087 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-245 DIVULG 07-10-2020 PUBLIC 08-10-2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. (...) NEGATIVA AO RECURSO EM LIBERDADE E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL NEGADO SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO". (HC 185181 AgR, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020).

Portanto, revogo a prisão preventiva dos réus FELIPE e PAULO HENRIQUE, determinando a imediata expedição do alvará de soltura.

O réu WELLINGTON também poderá apelar deste em liberdade em razão do regime inicial aberto imposto. Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei, observada a gratuidade processual ora concedida.

Defiro a incineração da substância entorpecente apreendida com as cautelas de praxe.

Decreto o perdimento do dinheiro apreendido e dos telefones celulares, porquanto fruto da traficância ilícita.

Após o trânsito em julgado, o nome dos réus deverá ser lançado no rol dos culpados.

Honorários da defensora nomeada no máximo da tabela (fls.227).

P.R.I.C.

Limeira, 26 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA